

1500104-50.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017187/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15764575 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 380/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2017187 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-50.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017187/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15764575 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 380/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2017187 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 208), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 215/217).

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2022 (fls. 218/219) e o acusado foi citado (fls. 261).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 277 e

297/298).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 303/307).

A defesa sustentou irregularidade na atuação policial e requereu o reconhecimento da nulidade da prova, com a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou para o descrito no artigo 33, § 3º, da mesma norma, e, no eventual caso de condenação, a fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 311/331).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/15), boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), fotografias (fls. 29/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119), laudo pericial (fls. 120/124) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos e aduziu que estava no interior de sua residência com o adolescente e Walter quando os policiais nela ingressaram sem autorização. Questionado sobre a existência de entorpecentes no local, respondeu que possuía duas porções de maconha para seu uso, de 15g cada. As porções de entorpecente retratadas à fls. 30 não eram as que tinha em sua residência.

Os policiais militares Willian e Daniel relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento e avistaram três indivíduos em pé junto ao portão de um imóvel que aparentava estar abandonado. Ao avistarem a viatura, dois deles ingressaram na casa, então abordaram o terceiro que saiu caminhando. Ele informou que estava ali para adquirir entorpecente e que havia entregado o dinheiro ao vendedor, mas optou por deixar o local ao ver a viatura. O portão da residência era de duas folhas e uma delas permaneceu aberta, sendo possível visualizar que um dos indivíduos dispensou algo no chão quando entraram. A sacola dispensada continha porções de maconha e de crack. Chamaram pelos rapazes que estavam dentro da casa, eles saíram e o réu admitiu estar vendendo entorpecentes com o auxílio do menor. Não entraram na residência por entenderem desnecessário, pois o acusado afirmou que não havia mais drogas no interior.

Walter narrou que estava na residência do réu para fumar um baseado por ele fornecido, mas não tinha conhecimento de que o imóvel era considerado uma "biqueira". Em determinado momento, ele e o adolescente saíram para comprar um lanche e, assim que retornaram, os policiais entraram no local sem autorização. Eles localizaram dois pedaços de 15g de maconha em cima de uma mesinha próxima da televisão, 5 pedras de crack armazenadas em uma sacolinha que estava no chão perto de um sofá que ficava do lado de fora, e dinheiro em uma sapateira. Tinha consigo 3 pedras de crack, que lhe foram dadas pelo réu pouco antes. O acusado disse aos policiais que a droga era dele. Não conhecia os policiais e eles não lhe pediram para dizer que a droga pertenceria a outrem, quando negou que fosse sua.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial, como sustentado pela defesa. Os policiais militares declararam que visualizaram os três indivíduos ao lado do portão de um imóvel conhecido como "biqueira" e que eles, ao notarem a

presença da viatura, deixaram o local, sendo que dois ingressaram na casa e um saiu caminhando pela via pública. Como o portão tinha uma das folhas aberta, puderam ver quando um dos dispensou um objeto ao chão. Optaram pela abordagem inicial da testemunha Walter, que relatou a intenção de comprar drogas no local e a entrega do dinheiro ao vendedor. Tais circunstâncias revelavam fundada suspeita da situação de flagrância e autorizavam o ingresso no local, corroborada pela identificação do objeto dispensado como sendo uma sacola contendo porções de maconha e crack.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INViolÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

[...] 3. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”. (STJ, HC 415.332-SP, 6ªT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julg. 16/08/2018).

No mérito, as provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

Ouvido em sede policial (fls. 12) o acusado, a despeito de negar o tráfico, afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes. Em seu interrogatório judicial, como se viu, alegou que em sua casa somente havia maconha para seu próprio consumo.

Sua versão, todavia, foi infirmada pelas provas produzidas.

A testemunha Walter, quando ouvida na delegacia (fls. 09), confirmou que estava adquirindo entorpecentes do réu e que, tão logo entregou o dinheiro a Welington, os policiais o abordaram. Na oportunidade, Walter detalhou como, anteriormente, tinha trocado com o acusado um agasalho da seleção brasileira por drogas e que, no momento dos fatos, havia retornado para adquirir mais entorpecentes, após conseguir dinheiro com um “corre”. Ele também relatou o encontro da sacola com algumas porções de maconha e crack, sacos plásticos e dinheiro. Walter aduziu, ainda, que o acusado sempre estava acompanhado do adolescente quando lhe vendeu droga, mas nunca comprou diretamente do menor.

Em juízo, como usualmente ocorre com usuário, provavelmente por medo, Walter alterou sua versão e apresentou contradições para tentar justificar a posse do agasalho com o logotipo da seleção brasileira pelo acusado, bem como sobre o que faziam quando os policiais chegaram. Observe-se que o acusado afirmou que já estavam comendo o lanche quando os policiais chegaram, enquanto Walter disse que os policiais ingressaram no local juntamente com o réu e o adolescente assim que eles retornaram. No mais, Walter confirmou que as porções de crack pertenciam a Welington e o encontro da sacola plástica com essa droga, tal como narrado pelos policiais e negado pelo réu.

De outro lado, as narrativas dos policiais se mostraram coerentes e harmônicas com as demais provas.

Cumprido desde logo observar que o réu não apontou motivo que justificasse a falsa incriminação por parte dos policiais, a quem sequer conhecia.

A destinação para entrega a terceiros restou demonstrada pela dinâmica da abordagem, pela diversidade de entorpecentes apreendida, sendo a maconha em porções individuais e outras maiores a serem fracionadas, além de apetrechos - sacos plásticos e tesoura - com resquício de maconha (fls. 120/124) e do encontro de dinheiro sem comprovação de origem lícita.

Assim, não há como acolher as teses defensivas de absolvição ou desclassificação, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado da denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a reprimenda de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

A despeito da alegação ministerial, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a tal atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa, a despeito dos indícios nesse sentido. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3 para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o crime envolveu adolescente, ao que majoro a pena de 1/6 para 2 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão e 263 dias-multa.

Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e dos motivos esposados na primeira fase.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer

a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal

- art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, o acusado WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO, qualificado nos autos, à pena de 2 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 263 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram a sua custódia cautelar (fls. 189/190), notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA